

1516945-67.2019.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516945-67.2019.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516945-67.2019.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2363864/2019 - DEL.SEC.AMERICANA

PLANTÃO, 9104851 - DEL.SEC.AMERICANA PLANTÃO, 13548/19/394 - DEL.SEC.AMERICANA

PLANTÃO, 2363864 - DEL.SEC.AMERICANA PLANTÃO, 13548/19/394 - DEL.SEC.AMERICANA

PLANTÃO, 2363864 - DEL.SEC.AMERICANA PLANTÃO, 13548/19/394 - DEL.SEC.AMERICANA

PLANTÃO, 2363864 - DEL.SEC.AMERICANA PLANTÃO, 13548/19/394 - DEL.SEC.AMERICANA

PLANTÃO, 2363864/2020 - DEL.SEC.AMERICANA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ANDERSON DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, 03 quilos e 500 gramas de fios elétricos,

avaliados em R\$100,00; 01 lâmpada fluorescente, avaliada em R\$20,00; e, 01 malote de couro, avaliado em R\$90,00; todos, bens pertencentes à empresa denominada HICOTEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. ME., não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 15 de maio de 2020 (fls. 127/128).

O réu não foi encontrado (fls. 146, 166 e 171), sendo citado por edital (fls. 182).

Foi determinada a suspensão do processo, bem como do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 190).

Com a localização do réu (fls. 215), foi nomeado defensor, o qual apresentou defesa prévia (fls. 135/137 e 224).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como o réu interrogado (fls. 276/277).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 281/285), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu pelo delito de furto qualificado tentado.

A Doutora Defensora (fls. 291/294) requereu a absolvição por ausência de provas, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, com a fixação de pena mínima e regime mais brando.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 01, 07/09 e 10/16, e laudo de fls. 110/120.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

“Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso)

(Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, o réu estava na posse do bem subtraído.

A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmutara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

A testemunha Celina, informou ser representante da pessoa jurídica, e ao chegar na empresa ouviu um barulho, tendo acionado a polícia. Disse que possibilitou a entrada dos policiais, e estes apreenderam uma pessoa dentro do imóvel, embaixo de uma escada na recepção. Disse, ainda, que verificou que perto do réu existiam duas bolsas de malote, sendo uma reconhecida, e contendo objetos subtraídos.

Não há nos autos prova de que a vítima/testemunha conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

O policial militar, ouvido em Juízo, esclareceu que foram informados de um possível furto em andamento, verificado pela proprietária, a qual ao chegar no estabelecimento, ouviu um barulho. Disse, ainda, que no local encontraram a proprietária, a qual possibilitou a entrada no imóvel. Declarou, também, que no interior do imóvel, na recepção, local onde fica a rede elétrica e de computadores, localizaram o réu, tentando se esconder sob a escada. Em vistoria, constataram que o portão dos fundos estava danificado, com um buraco, e verificaram que uma parte do muro estava danificada, possivelmente pela escalada. Próximo ao réu, encontravam-se dois malotes, um deles foi reconhecido pela proprietária, e em seu interior estavam fiação e lâmpada, além de verificarem fiação cortada pelo estabelecimento. Por fim, indagado, o réu alegou que adentrou o local para dormir.

Não procedem as alegações da defesa quanto à imprestabilidade dos depoimentos do policial. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).(...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

O réu Anderson, ouvido em Juízo, negou a prática do furto, informando apenas acerca da invasão pelos fundos, alegando, no entanto, que o local estava aberto e foi apenas para dormir. Alega que estava deitado quando da abordagem pelos policiais, e não tinha nenhuma mochila. Por fim, declarou que a empresa encontra-se fechada há algum tempo.

O réu apresentou "álibi" (adentrou o local apenas para dormir), sem, no entanto, comprová-lo. A alegação não comprovada de álibi é também indício que milita em desfavor do réu.

De acordo com a doutrina:

"No terreno do processo penal há uma forma de defesa que é exclusiva e passou a ser conhecida como o 'álibi'.

Álibi, etimologicamente, significa em outra parte, em outro local. A princípio consistia uma exceção oferecida pelo acusado mediante a qual afirmava que, ao momento do crime, estaria em outro local, portanto, impossível sua participação. Com o decorrer do tempo ampliou-se seu significado, passando a representar toda alegação fática feita pelo acusado visando demonstrar a impossibilidade material de ter participado do crime.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constituiu uma exceção de defesa e, como tal, cabe ao inculpatado o ônus de sua demonstração.

'Imperativa é a jurisprudência no sentido de que, quem apresenta um álibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, pena de ser tido como réu confesso' (JTACrim 54:204). Completando: JTACrim, 47:165, 33:334 E 22:77." (CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. de, Da prova no Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.18)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal. Autoria e Materialidade comprovadas. Palavra guarda municipal. Validade Precedentes. Ademais, o acusado foi encontrados na posse do objeto receptado. Incabível a alegação de insuficiência probatória. Álibi não comprovado. Inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal. Pena. Dosimetria. Reprimenda aplicada de forma adequada. Substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direito. Impossibilidade. Acusado reincidente em crime doloso. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação nº 0008542-14.2014.8.26.0229, da em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Silmar Fernandes, Data: 29/11/2018).

Estelionato - Vítima iludida e orientada a depositar valor na conta do réu para receber indenização judicial - Prova segura e coerente - Álibi do acusado fantasioso e não comprovado - Condenação mantida - Recurso provido em parte para adequação da pena, com reconhecimento da prescrição. (Apelação nº 0005053-20.2009.8.26.0495, da 11ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Alexandre Almeida, data: 01/12/2017).

PROVA - Invocação de alibi - Circunstância que resta indemonstrada - Formação de indício contra o réu - Entendimento:118 - Quem invoca alibi, para recusar a co-autoria, ou a participação em delito, não o provando, faz despontar indício de má justificação, a ser utilizado contra o réu. RJDTACRIM VOLUME 16 OUTUBRO/DEZEMBRO/1992 PÁGINA: 214 RELATOR: - SÉRGIO PITOMBO

Além desses indícios, existe outro forte indício, que é a pretérita condenação do réu pela prática de crimes contra o patrimônio o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

PROVA - Maus antecedentes - Valor: 30(d) - Os antecedentes negativos não servem de base exclusiva para decreto condenatório mas constituem importante adinículo para a formação do convencimento. (Apelação nº 1.171.909/6, Julgado em 03/02/2.000, 7ª Câmara, Relator: Corrêa de Moraes, RJTACRIM 47/133)

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado, inclusive acerca das qualificadoras (escalada e arrombamento), tendo em vista a comprovação pelas declarações iniciais, reforçada pelas testemunhas.

Apesar da possibilidade de o réu ter acabado por pegar no sono, a indicação de que o imóvel encontrava-se com portas danificadas, além de objetos revirados e separados para a subtração, refutam as alegações da defesa acerca de ausência de provas.

Assim, não obstante as alegações da defesa, não é possível a absolvição pelo delito ou sua desclassificação, tendo restado comprovada a entrada sem autorização e a separação dos objetos com a intenção de subtração.

Ainda, as qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo encontram-se demonstradas pela prova testemunhal, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, bem como pelo laudo de fls. 110/120, não havendo falar-se em qualquer afastamento de qualificadora.

Por fim, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, qual seja, o de ter sido surpreendido pelos policiais.

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 25/36) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. No mais, em se tratando de furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e escalda), há maior reprovabilidade da conduta do acusado. Exaspero, por isso, a pena base na 1/5 (um quinto), delimitando-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem."

(Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 25/36. Acrescento à pena base, portanto, mais 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e catorze dias-multa.

Tendo em vista que o delito se deu na forma tentada, diminuo a pena de 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido, que se aproximou sobremaneira da consumação, porquanto chegou a destruir o obstáculo e separar objetos para a subtração, perfazendo assim um total de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Não é possível o reconhecimento do privilégio constante do § 2º, do artigo 155, do Código Penal em caso de furto qualificado. Além disso, para que o benefício fosse concedido, é requisito que o réu seja primário e portador de bons antecedentes. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação da figura do furto privilegiado é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída.

2. No caso, um dos réus é reincidente e o valor da coisa subtraída, somado ao prejuízo suportado pela vítima para o conserto de sua residência em razão do arrombamento, não pode ser considerado pequeno para fins de reconhecimento do privilégio pleiteado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RESp 1511869/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 155, § 2º, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes. 2. Segundo jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno pode incidir tanto no furto simples quanto no qualificado, inexistindo incompatibilidade entre os institutos. Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido. (RESp 1724648/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

FURTO QUALIFICADO - Reconhecimento do privilégio - Impossibilidade: 9(b) - É impossível a concessão do privilegium do art. 155, § 2º, do CP às hipóteses de furto qualificado, máxime se o prejuízo suportado pela vítima superar o salário-

Ademais, os péssimos antecedentes do réu desaconselha a adoção de tal benefício.

À míngua de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto em razão de ser o réu reincidente.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu ANDERSON DA SILVA à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 09 (nove) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.
P. I. C.

Americana, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA